



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק מס': 84/05

בענין:

1. **יוסי גולדברג**

מרח' קדימה 7, חיפה 34382

2. **יהודית וייס**

מרח' פנקס 38, תל-אביב 62261

3. **קלרה שטג**

מרח' קדימה 7, חיפה 34382

מען לדואר: תובעים 1 ו-3

התובעים

נ ג ז

מרדכי ושולמית פרלמן

ע"י ב"כ עוה" שרויאר ואח'

מרח' אלנבי 22, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ז י נ

1. הליך זה נפתח בכתב תביעה שהגישו בעלים של 4 דירות בבית משותף נגד בעלים של דירה אחרת באותו בית משותף, בו עתרו לצו שיאסור על האחרונים הרחבת דירתם בדרך של בניה ברכוש המשותף. נכון לעת הגשת כתב התביעה לא היה בידי הנתבעים עדיין היתר בניה, אך במהלך הדיון אושרה להם על ידי רשויות התכנון הרחבת דירה בתנאים כמפורט בהחלטת הרשות, וההליך דנא מטרתו לקבוע אם יש לנתבעים זכות לממש את היתר הבניה שקיבלו, אם לאו.
2. נטען בכתב התביעה כי הנתבעים אינם עומדים בתנאי הסף של הפרק בחוק המקרקעין הדרוש בשינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה. מטעם זה אין להם זכות להרחיב את דירתם לעבר ועל חשבון הרכוש המשותף.
3. בהגנתם טוענים הנתבעים כי הגישו בקשה לתוספת בניה בהסתמך בין השאר על הסכמתם של התובעים, בין אם הסכמה מפורשת ובין אם מכללא. ההסכמה מיוחסת לתובעת מס' 2 שהנה בעלים של שתי דירות בבית המשותף. אישור נוסף לבקשת הבניה של הנתבעים ניתן על ידי התובעים, כך בכתב ההגנה, במסגרת אסיפה כללית של בעלי הדירות שהתכנסה בחודש נובמבר 2003. באותו המעמד לא הובעה מצד אף לא אחד מבעלי הדירות התנגדות לתוכנית הבניה שעיקריה הוסברו בעל פה ובהצגת תשריט. התובעים ובעיקר תובעת מס' 2 אינם זכאים לחזור בהם מההסכמה שנתנו, שכן הנתבעים הסתמכו עליה ופעלו על פיה.

4. הבית המשותף הנדון נמצא ברח' קדימה 7, חיפה ומזוהה כחלקה 78 בגוש 10910. על פי מרשם המקרקעין הבית מונה 6 דירות, 2 מהן בבעלות תובעת מס' 2 (להלן: "התובעת"), ודירה אחת בבעלות כל אחד מהצדדים האחרים להליך. בעלי דירה אחת, יחידת משנה 3, איננו צד להליך, שכן נתן הסכמתו לבניה המתוכננת על ידי הנתבעים.
5. הנתבעים 1 ו- 3 ויתרו בשלב כזה או אחר ומנימוקים כאלה ואחרים על התביעה; נותרה התובעת, עומדת על זכויותיה לסעד כמפורט בכתב התביעה.
6. התקיימו בפניי ישיבות למכביר וחקירות למכביר. כמו כן, הוצגו בפניי ראיות למכביר, כשכל צד מבקש להסיק מהן מסקנות התומכות בעמדתו שלו, לאמור:
- (א) התובעת עמדה על הטענה כי מעולם לא ניתנה, לא על ידה ולא על ידי בעלה המנוח, הסכמה כלשהי לרבות לא ברמה הנדרשת על פי דיני המקרקעין, לבניה המבוקשת על ידי הנתבעים.
- (ב) הנתבעים עמדו על הטענה כי ראשיתה של יוזמת ההרחבה בשיתוף פעולה הדוק של הנתבע עם בעלה של התובעת, ניתנה הסכמתו להרחבה המתוכננת, והסכמה זו מחייבת גם את התובעת שמעולם לא התעלמה ולא חזרה בה ממנה.

המסגרת הנורמטיבית:

7. שני נתונים מצטברים מהווים תנאים הכרחיים להשתכללות זכותו של בעל דירה לבנות ברכוש המשותף, ואלו הם: הזכות נתמכת בהסכמה של רוב של לפחות 75% מבעלי הדירות וכן נתמכת במי ש-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. ראה סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, הוראת דין שהוכנסה במסגרת תיקון 18 לחוק. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת.
8. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף.

9. קנין הוכר בדין כזכות יסוד הראויה להגנה אך דיני הקנין של המשפט הפרטי, ובמקרה הזה חוק המקרקעין, הם שקובעים את הקריטריונים להגנה על זכות זו. ראה ברק, פרשנות במשפט, כרך ג', עמ' 786 ואילך. בפרק בחוק המקרקעין הדין במימוש זכויות בניה (בין אם נילוה להן אחוזי בניה ובין אם לא) נקבעה מערכת של איזונים מהותיים אשר נועדה להקטין את הפגיעה בקנין שנגרמת בעטייה של בניה ברכוש המשותף. המלומד דויטש בספרו קנין, כרך א', עמ' 701 בוחן אחת לאחת אם תנאי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נשמרים בתיקון 18 לחוק המקרקעין ומוצא כי התיקון הוא תקף.
10. בע"א (חי') 1725/05 דוד נ' נברוצקי (השופטים גריל חופרי ופינקלשטיין) פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראה למשל ע"א 2111/03 פליצייה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע. התיקון נועד לאפשר לבעל דירה המשיג הסכמה של לפחות 3/4 מבעלי הדירות (כולל הדירה נשוא ההרחבה) שיש להם לפחות 2/3 מן הרכוש המשותף לבצע הרחבה בדירתו (סעיף 71ב' של חוק המקרקעין). סימן ג'1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש (ראה בענין זה בספרו של המלומד מיגל דויטש, קנין חלק א' תשנ"ז-1997)....".

11. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה קיימת מצריכה הסכמה למצער של 3/4 מבעלי הדירות. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית; אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאים שהיא קובעת.

12. אף זאת לפי הפסיקה, אין להסיק מהיעדר התנגדות או מיישיבה על הגדרי קיומה של הסכמה פוזיטיבית. זאת לזכור כי עסקינן בזכויות קנייניות ששינוי בהן מחייב הסכמה ברורה, מוגדרת, חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים. ראה ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי נ"ד(3) 389 השופטת דורנר :

"גישת פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות **מפורש**". (ההדגשה שלי – צ.פ.).

ועוד ראה חוות דעתו של כב' הנשיא דאז שמגר בע"א 239/79 - ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2), 807 שם נפסק :

"כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוק ובדיק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא. "

13. וכן ראה פסק דינו של כב' השופט דר' בנימיני בה"פ 1266/03 (מחוזי ת"א) מיום 25.11.07 והפסיקה הענפה אליה הוא מפנה בפרקים 18-19 לפסק הדין.

14. יוצא מכאן כי אמנם מקום שתפיסת החזקה ברכוש המשותף נועדה לשם הרחבת דירה קבע החוק הסכמה מופחתת, אך עדין צריכה זו להיות הסכמה, ולא הימנעות מהתנגדות.

בחינת חומר הראיות:

15. אקדים ואומר כי הוגשו בתיק זה ראיות למכביר, לא אחת הוגשה אותה ראיה מספר פעמים כשבכל פעם צוינה בסימן זיהוי שונה. הראיות בהן מצאתי לעגן את המסקנות אליהן אני מגיעה בפסק הדין הן אלו :

(א) בקשה לקבלת מידע שהוגשה על ידי בעלה של התובעת למחלקת התכנון והבניה, נושאת תאריך 15.01.89 ומכתב התשובה לאותה פניה – נ/3.

(ב) הסכם להזמנת שירותי מתכנן בין הנתבעים לבין האדריכלית נושאת תאריך 10.09.1995 – ת/28.

- (ג) הצעת מחיר של הארכיטקט כרמי ממוענת לבעלה של התובעת ולנתבע, נושאת תאריך 12.10.95 – ת/27.
- (ד) הסכם להזמנת שירותי מתכנן בין התובעת ובעלה המנוח לבין האדריכלית נושאת תאריך 03.03.96 – ת/21.
- (ה) דרישת תשלום של האדריכלית אל הנתבעים וכן חשבונית מס נושאים תאריך 07.01.97 ו- 01.03.97, בהתאמה – ת/30, ת/29.
- (ו) בקשה להיתר בניה ולפיה הנתבעים הם המבקשים, נערכה על ידי צרף-נתניהו (האדריכלית) ונחתמה על ידי ביום 01.10.2003 – היא הבקשה המהווה בסיס לדיון.
- (ז) מכתב של הנתבעים אל התובעת נושא תאריך 30.11.03 אליו מצורפים (כמצוין במכתב עצמו) העתקי הבקשה להיתר בניה והנחיות העירייה – ת/10.
- (ח) סיכום ידני של ישיבה מיום 15.11.03 – ת/13.
- (ט) סיכום מודפס של ישיבה מיום 15.11.03 – ת/14.
- (י) מכתבם של הנתבעים אל מזכיר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נושא תאריך 11.05.2005 – ת/25.
- (יא) פרוטוקול וועדת משנה של הוועדה המקומית מיום 12.09.05 – ת/9.
- (יב) הצעת מחיר לשיפוצים של האדריכלית נושאת תאריך 18.01.96 – נ/1.
- (יג) דרישת תשלום של האדריכלית מופנית למשפחת התובעת ושתי חשבוניות מס נושאות תאריכים 03.03.96 ו- 01.11.96 – נ/2.

16. עמדות הצדדים בסיכומי הטענות :

(א) התובעת מבקשת להסיק מחומר הראיות כמו גם מהעדויות שנשמעו, כי בשום שלב לא הייתה הסכמה לבניה המתוכננת על ידי הנתבעים, לא מצדה ולא מצד בעלה המנוח, לא הסכמה מפורשת ולא הסכמה משתמעת. הבניה המתוכננת התגבשה אצל הנתבעים באופן חד צדדי והוצגה לה, כמו גם ליתר בעלי הדירות, לאחר שכבר הוגשה לרשות התכנון על ידי הנתבעים.

(ב) הנתבעים מנגד מבקשים להסיק מחומר הראיות הסכמה מצד בעלה של התובעת וכן הסכמה מצדה שלה, שכן הייתה מודעת להליכים שנקטו על ידי בעלה המנוח, לבירור זכויות ואפשרויות בניה בפניה משותפת שלהם ושל הנתבעים לשני מתכננים. הנתבעים הסתמכו על עמדה עקבית חיובית של התובעת לאורך שנים, כשלראשונה התוודעו להתנגדותה רק בחודש פברואר 2005 כאשר נתבקשה לחתום על טופס ההסכמה לעיריית חיפה. בשום הזדמנות קודמת בה עלה נושא הבניה המבוקש על ידי הנתבעים על הפרק בין אם בפורום אסיפת הדיירים ובין אם במכתב אישי אליה, לא הביעה התובעת התנגדות לתוכנית הבניה של הנתבעים.

דיון

17. עיינתי בכל החומר שהונח בפניי, חקירות עדים ומסמכים, ויישום ההלכות המשפטיות על כל הללו מביא אותי למסקנה שדין התביעה להתקבל שכן לא הוכחה הסכמה מפורשת של התובעת לתוכנית הבניה העומדת על הפרק. אלה נימוקי החלטתי:

(א) סקירת התקדימים אליהם הפניתי מדגישה כי הסכמה בדבר ויתור על זכויות קנייניות, ובנייה של בעל דירה ברכוש המשותף מהווה במובהק ויתור של בעל דירה אחר באותו רכוש משותף, ולכן חובה שתהיה מוגדרת, מפורשת חד-משמעית ואינה משתמעת לשתי פנים.

(ב) אכן ניתן להתרשם כי כבר בסוף שנות ה-80 וכן באמצע שנות ה-90 יזמו משפחת התובעת וכן הנתבעים פניה לארכיטקטים כדי לבחון אפשרויות בניה, כל אחד על פי זכויותיו הקנייניות במקרקעין. מאחר ונכון לעת ההיא היה זה מעניינם של שני בעלי הדירות, ולאור העובדה שדירותיהם בנויות אחת מעל השניה, באותו אגף של הבית המשותף, אך טבעי היה שיפנו לאותו בעל מקצוע כדי שיבצע עבורם את הבדיקות המתאימות אצל רשויות התכנון וייעץ להם אודות אפשרויות הבניה העומדות לכל אחד מהם.

(ג) ואולם מהמסמכים עולה כי בשום שלב לא התגבשה בין משפחת התובעת לבין הנתבעים הסכמה בדבר המשך תכנון או תכנון פרטני של כל אחת מדירותיהם. מדובר היה בשלב של "גישוש" האופציות השונות העומדות לכל אחד מהם למול רשויות התכנון. לא באה בפניי שום הוכחה שהצדדים האמורים הסכימו ביניהם איזו אופציה תאומץ על ידי כל אחד מהם, לא כל שכן הסכמה של האחד לאופציה שתאומץ על ידי משנהו. גם הנתבעים באותו שלב לא גיבשו עם עצמם החלטה בדבר אופן מימוש זכויות הבניה שביירו כי עומדות להן; ההמלצה של הארכיטקטית קרמה אצלם עור וגידים באופן שבא לידי ביטוי חיצוני בגרמושקה לכל המוקדם בחודש אוקטובר 2003 בעת שלראשונה ערכה בקשה להיתר בניה ערוכה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות).

(ד) הגרמושקה נערכה כאמור לבקשת הנתבעים מבלי שבאה כל ראייה לכך שכבר הייתה "בצנרת" אצל הארכיטקטית גרמושקה עבור משפחת התובעת. נתון זה עולה בקנה אחד עם טענת התובעת ולפיה היא ובעלה זנחו את תוכניות הבניה.

(ה) הצעת המחיר של הארכיטקטית מדברת על מסגרת כללית ביותר ומביאה פרטים אודות המתחייב מהליך בקשה להיתר בניה המוגשת לרשות התכנון, אופציות כלליות שעומדות למבקש כגון תוספת מעלית, תוספת קומה, נתונים אודות שטחים שלא כלולים ברישוי, חריגות מקו בניין, חישוב שטחים אופציונאליים בשים לב לנתוני שטח המגרש, השטח המותר לבניה ונתונים אחרים, ומכל מקום, בשום שלב לא הוכנה על ידי הארכיטקטית גרמושקה המדגימה הצעה אופרטיבית להרחבת דירות שני הצדדים בצוותא חדא כהמשך ליוזמה המשותפת משכבר.

(ו) הגם שהגרמושקה נערכה בחודש אוקטובר 2003, היא לראשונה הובאה לידיעת התובעת רק בחודש דצמבר 2003 במצורף למכתב בו מבקשים הנתבעים מהתובעת ליתן הסכמתה לבניה המתוכננת (ת/10). מכתב באותה הלשון ממש נשלח גם אל בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, ומשפט הסיום בו: "אנו תקווה שתביעו את הסכמתכם על מנת שנוכל לקבל בהקדם את היתר הבניה". אילו הייתה התובעת במעמד של מי שכבר הסכים ליוזמת הבניה, כטענת הנתבעים, מה טעם מצאו לפנות אל התובעת באותו הנוסח שפנו אל בעלי הדירות לגביהם אין טענה של הסכמה משכבר? פשיטא שגם הנתבעים לא ראו בתובעת מסכימה.

(ז) בחינת פרוטוקול אסיפת הדיירים מחודש נוב' 2003, בין אם זה הכתוב בכתב יד, ובין אם זה המודפס, מדגימה אך את פנייתם של הנתבעים בהודעה לנוכחים על כוונתם להרחיב את דירתם. הכתוב לא מהווה ראייה להסכמה של מי מהנוכחים, לא הסכמה משתמעת ולא כל שכן הסכמה מפורשת. וכבר הראינו בפסיקה דלעיל כי הסכמה בדבר ויתור על זכויות קניין חייבת להיות מפורשת ומדעת. יתרה מכך, סוף הפרוטוקול מציין כי מתוכננת אסיפת דיירים נוספת לסוף חודש דצמבר אותה השנה, חיזוק נוסף לטענה שנושא הרחבת דירת הנתבעים לא לובן סופית.

(ח) ת/9 מגדיר את מהות הבקשה שהוגשה על ידי הנתבעים לרשויות התכנון, וזה תוכנה: מבקשים לאשר שינויים פנימיים וחיצוניים לדירה קיימת בקומת הקרקע וכן תוספת בניה בקומת הקרקע + מחסן וקומת עמודים + פרגולה וכן שינויים בפיתוח כשהבקשה כרוכה בעודף שטח, בתוספת קומת עמודים פרטית, ובבליטה למרווח האחורי. לפירוט זה אין שום רמז בנייר העבודה שהגישה הארכיטקטית לצדדים, בו רואים הנתבעים בסיס להסכמה, שמבחינתי אינו אלא חוות דעת כללית התואמת את מה שהוזמן אצלה באותו שלב.

(ט) ההסכם להזמנת שירותי מתכנן שהוא לכאורה השלב הבא לאחר קבלת חוות הדעת של הארכיטקטית, אפילו הוא נחתם כבר באופן נפרד כשכל אחד מהצדדים חותם על הסכם נפרד (ת/21). לדעתי כבר אז נפרדו דרכיהם של הצדדים מבחינת התכנון. ומכל מקום, אין שום ראיה לכך שהנתבעים תיאמו את יישום ההמלצות של הארכיטקטית עם התובעת או תכננו את הרחבת דירתם תוך יידוע התובעת בזמן אמת, כמי שלכאורה שותפה להם – כטענתם – ביוזמת הבניה.

(י) ראיתי לציין את ההתכתבויות של התובעת וכן של הנתבעים עם רשויות התכנון רק כדי להדגיש כי אינני רואה בהתכתבויות הללו בסיס ראייתי להסקת מסקנה כלשהי, בדבר הסכמה או העדר הסכמה של התובעת; ממילא לא מצאתי כי התובעת אי פעם הסכימה ליוזמת הבניה של הנתבעים כפי שמוצאת ביטוי בגרמושקה, ותוכן המכתבים רק מחזק זאת. אסתפק בהפניה לסעיף 5 מ-ת/25 בו כותבים הנתבעים למזכיר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כי "חשוב לציין במפורש בקשה זו היא נגזרת מתוך תוכנית מוסכמת..." (ההדגשה שלי – צ.פ.), מה שמחזק את המסקנה שהבקשה עצמה אינה בקשה מוסכמת, לא מלכתחילה ולא בדיעבד.

18. מכל הנימוקים דלעיל, מאחר ולא שוכנעתי כי התובעת הסכימה בשלב כלשהו לבקשה להיתר בניה שהוגשה על ידי הנתבעים, ובהעדר הסכמה שלה ממילא לא עומד לזכותם הרוב הקבוע בסעיף 71ב' (א) לחוק המקרקעין, אני מקבלת את התביעה ונותנת צו האוסר על הנתבעים יחד ולחוד, לממש את היתר הבניה שהוצא להם על פי בקשה מס' 41/0479/02.

19. בשל סירבול ההליכים שנגרם לא מעט לאור התנהלות התובעת בתיק זה, ראיתי לא לזכות אותה בהוצאות משפט.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כד' בכסלו התשס"ח (04.12.07).
העתקים יישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים

מפקחת על רישום מקרקעין